

次の【事例】における実況見分調書が、立証趣旨を「犯行現場の状況」として、その証拠調べを請求され、刑事訴訟法第321条第3項による書面として証拠調べされた場合、後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

甲は、午後6時30分ころ、X交差点において、自動車を運転中に交通事故を起こして被害者を死亡させた。司法警察員Kは、甲を被疑者とする業務上過失致死被疑事件について、犯行現場の状況を明らかにするために、同現場において、事故直後の午後7時から40分間にわたり、甲を立ち会わせて実況見分を行った。Kは、その後、その経過と結果を正確に記載した実況見分調書を作成した。この実況見分調書には、次の(a)から(e)までの各記載があり、現場見取図が添付されているが、甲の署名押印はない。

- (a). 甲は、同現場交差点南側の街灯を指さして「事故当時、この街灯は点灯していませんでした。」と説明した。
- (b). 甲は、「私が被害者を初めて発見した場所は①地点でした。その時、被害者が立っていた場所は②地点でした。」と説明した。
- (c). Kが、①地点と②地点の間の距離を測定したところ、10.7メートルであった。
- (d). Kが、①地点の運転席に着席した甲の目の高さに視線を置き、②地点方向を見たところ、道路脇に設置された看板の陰になって、②地点の路面は見えなかったが、高さ80センチメートルを超える部分は見えた。
- (e). 実況見分を実施している間、本件現場付近の人通りは多かった。

【記述】

- ア. この実況見分調書中の(a)の記載を、当該街灯が事故当時点灯していなかったという事実の認定に用いることができる。
- イ. この実況見分調書中の(b)の記載を、甲が初めて被害者を発見したときに、被害者は②地点に立っていたという事実の認定に用いることができる。
- ウ. この実況見分調書中の(b)及び(c)の記載を、甲が初めて被害者を発見した場所として指示した地点とその際に被害者が立っていた場所として指示した地点の間の距離が10.7メートルであるという事実の認定に用いることができる。
- エ. この実況見分調書中の(d)の記載を、①地点の運転席に着席していた甲からは②地点の路面を見通すことができないという事実の認定に用いることはできない。
- オ. この実況見分調書中の(e)の記載を、事故直後の午後7時から40分間、本件現場付近の人通りは多かったという事実の認定に用いることができる。

1. ア イ 2. イ ウ 3. イ エ 4. ウ エ 5. ウ オ

本問においては、実況見分調書が321条3項による書面として証拠調べされている。実況見分調書は、実況見分を行った者が場所、物、又は人の形状・性質を五官の作用で感知した結果について記載した供述書であり、伝聞証拠であるが、任意処分か強制処分かという点で検証と異なるにすぎず、場所、物、又は人について、その形状・性質を五官の作用で感知するという活動の性質についての差異はない。そして、書面による報告に親しみ、また技術的事項に関することゆえ恣意の入る余地が少ない点でも検証と同様である。したがって、321条3項の書面に含まれ、伝聞例外として証拠能力が認められる。判例も、「刑訴321条3項所定の書面には捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記載したいわゆる実況見分調書も包含する」としている（最判昭35.9.8、百選A38事件）。

そして、実況見分の立会人が指示説明をしている場合、立会人の指示説明は、それが純粹に実況見分の対象を確定する必要からなされるいわゆる「現場指示」であれば、実況見分の結果そのものとして調書に記載することももとより許される（最判昭36.5.26参照）が、右のような指示を超えるもの、すなわち「現場供述」であれば、その部分は供述録取書の性格をもつから321条3項によっては証拠能力をもち得ず、調書に記載することも相当でないと一般にいわれている。

そして、指示説明が現場指示の程度を超えていない場合、立会人の指示説明が実況見分の動機・手段である場合には、指示説明も結局は実況見分の結果を記載したものに他ならないから、321条3項によって証拠能力は認められるが、それを供述内容の真実性を証明するための証拠として用いる場合には、供述証拠としての利用に他ならないから、326条の同意を得るか、立会人が被疑者であれば322条1項の要件を、第三者であれば321条1項2号ないし3号の要件をみたすことが必要となる（最決平17.9.27、百選82事件参照）。ただし、本問では立会人甲の署名押印はないため、その点で要件を欠くことになる。以上を前提に各記述について検討する。

ア 誤っている

(a)の甲による「事故当時、この街灯は点灯していませんでした。」という供述は、立会人の指示説明のうち、実況見分の対象を確定したものとして現場指示にあたるといえる。しかし、事故当時点灯していなかったという事実の認定に用いる場合には、供述内容の真実性を証明するための証拠として用いる場合に当たるから、供述証拠としての利用に他ならず、322条1項の要件をみたさなければ証拠とすることはできない。したがって、本記述は誤っている。

イ 誤っている

(b)の甲による「私が被害者を初めて発見した場所は①地点でした。その時、被害者が立っていた場所は②地点でした。」という供述は、立会人の指示説明のうち、実況見分の対象を確定したものとして現場指示にあたるといえる。しかし、甲が初めて被害者を発見したときに、被害者は②地点に立っていたという事実の認定に用いる場合には、供述内容の真実性を証明するために用いる場合に当たるので、供述証拠としての利用に他ならず、322条1項の要件をみたさなければ証拠とすることはできない。したがって、本記述は誤っている。

ウ 正しい

(c)は、実況見分者が、(b)の立会人の指示説明に基づき①②地点の距離を測定した結果の記載である。指示説明に基づき特定された地点と測定の結果とを合わせて「①②の距離が10.7メートルである」旨を認定するのであれば、証拠として使用されたのは指示説明の結果明らかになった位置及び計測の結果であり、指示説明を供述内容の真実性を証明するために用いる場合に当たらない。よって、321条3項により証拠として用いることができる。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

(d) は、実況見分を行った者が場所の形状・性質を五官の作用で感知した結果について記載したものであるから、実況見分の結果そのものとして、321 条3 項により証拠とすることができる。したがって、本記述は誤っている。

オ 正しい

(e) は、実況見分を行った者が場所の性質を五官の作用で感知した結果について記載したものであるから、実況見分の結果そのものとして、321 条3 項により証拠とすることができる。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述はウとオであり、したがって、正解は肢5 となる。

